

1500325-14.2020.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500325-14.2020.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500325-14.2020.8.26.0546

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ABIMAEEL GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Abimael Gomes da Silva, menor de 21 anos de idade, foi denunciado e está sendo processado porque, no dia 20 de novembro de 2020, por volta das 23h00min, na Rua Domingos Toso, 170, Jardim América, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de estabelecimentos de ensino, de local de trabalho coletivo e de recintos onde se realizam diversões de qualquer natureza, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 54 (cinquenta e quatro) microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 39g (trinta e nove gramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls.113), apresentou defesa prévia (fls. 119/127) e a denúncia foi recebida (fls. 133/134).

Houve citação (fls.152).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas, com o interrogatório do réu ao final.

A representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, condenando o acusado nos termos descritos pela denúncia, com imposição do regime

inicial fechado para cumprimento de pena, afastando-se o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei antidrogas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da lei nº 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08); pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 09); laudo pericial do local dos fatos (fls. 73/78); laudo de exame químico toxicológico (fls. 70/72) e por toda a prova oral colhida em juízo.

Maicon André Souza de Abreu Fernandes, guarda civil municipal, disse que estava em patrulhamento pelo local e visualizou o acusado, que foi abordado. Em sua mão, localizou 7 pinos contendo substância parecida com cocaína e dez reais. Em local próximo, em um muro, localizou mais 47 porções embaladas de maneira idêntica. Já havia abordado o acusado e nada ilícito localizado anteriormente. Não havia outras pessoas nas imediações.

Henrique da Silva, guarda civil municipal, disse que estava em patrulhamento por local onde é comum a venda de drogas. Avistou o acusado, que, ao perceber a presença da viatura, tentou deixar o local, mas foi abordado. Em busca pessoal, apreendeu sete microtubos contendo substância semelhante à cocaína. Apreendeu dinheiro e, do outro lado da via, apreendeu mais porções escondidas em um muro, que estavam embaladas de maneira idêntica às aquelas apreendidas em sua posse direta. Não se recorda se havia outras pessoas perto do muro.

Em solo policial, o acusado Abimael Gomes da Silva preferiu permanecer calado (fls.06).

Em juízo, o acusado disse que portava apenas seis pinos de cocaína e que eles se destinavam a seu consumo pessoal. Nega envolvimento com as demais 47 porções apreendidas, as quais não lhe foram exibidas e afirma terem sido apreendidas em outro bairro. Mora nas imediações do local onde se deu a abordagem.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas civis é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico em razão da quantidade e forma como as drogas estavam embaladas, tratando-se de porções fracionadas.

De se anotar que a alegação do acusado no sentido de que a maior parte das porções foi apreendida em outro bairro não restou minimamente comprovada e a respeito dela existe apenas a versão do increpado.

Ao contrário disso, os guardas civis disseram que, além das porções apreendidas na mão do acusado, também apreenderam mais 47 porções de cocaína em muro perto de onde estava o acusado, sendo que todas as porções estavam embaladas de maneira idêntica, circunstância que permite imputar o crime descrito na denúncia ao acusado.

Exatamente por isso, inviável cogitar da desclassificação para a figura prevista no art. 28 da lei n. 11.343/06, na medida em que a quantidade apreendida (47 porções) é incompatível com aquela finalidade.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo e guardava quantidade expressiva de drogas acondicionadas de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663). “Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas civis, na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes, de modo que não se vislumbra nenhum indício para os servidores públicos imputarem falsamente o crime ao acusado.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade no mínimo legal, já que a quantidade de entorpecentes apreendidos não destoa significativamente do que normalmente se vê em casos semelhantes, pois a massa bruta verificada é de pouco mais de 40 gramas (fls. 71).

Nesse cenário, fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes a reconhecer, mas está presente a atenuante da menoridade relativa, que não tem reflexo na pena inicialmente fixada (súmula 231 do STJ).

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, Lei n. 11.343/06 já que o laudo pericial do local revela que nas imediações estão localizados estabelecimentos de ensino, local de trabalho coletivo e praças públicas o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas.

Aliás, a lei não exige que o estabelecimento de ensino seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Por outro lado, entendo possível a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º da lei n. 11.43/06, com redução da pena em 2/3, resultando pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa. Isso porque, embora tenham sido impostas medidas socioeducativas perante o juízo da infância e juventude local em desfavor do acusado, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, os documentos de fls. 176/179 revelam que aquela condenação se refere a fato ocorrido mais de quatro anos antes da conduta apurada nos presentes autos.

Nesse contexto, é de se anotar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, fixou o entendimento de que o benefício previsto no art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, pode ser denegado ao agente condenado perante o juízo da infância e juventude quando, dentre outros requisitos, se verifique a proximidade temporal entre os atos apurados. A esse respeito:

6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EResp n. 1.916.596/SP, 3ª Seção, julgado aos 8/9/2021, Rel. para acórdão Ministra Laurita Vaz).

Por este fundamento, entendo ausente um dos requisitos fixados pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o benefício não pode ser afastado no caso dos autos, já que o intervalo entre as condutas apuradas é de mais de quatro anos sem que, no intervalo, exista notícia de novos atos infracionais ou fatos criminosos praticados pelo agente.

Em razão da quantidade imposta, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto, pois esse é entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu Habeas Corpus coletivo para proibir que os juízes e desembargadores da Justiça de São Paulo apliquem regime fechado a presos enquadrados no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), estendendo, inclusive, aos condenados que já cumprem pena nessa situação, conforme a seguinte ementa:

"PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1)."

O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que o réu faz jus à aplicação do artigo 44 do Código Penal.

Substituo, portanto, a pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo mesmo período da privativa de liberdade, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, e pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a entidade pública ou privada, com destinação social.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Abimael Gomes da Silva à pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em

regime inicial aberto, e pagamento de 194 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma da fundamentação.

O réu poderá recorrer desta em liberdade.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois consequência lógica da condenação imposta, bem como porque não há sequer indícios de sua origem lícita. Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 04 de maio de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA